

1500516-98.2022.8.26.0575
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES
Comarca: São José do Rio Pardo
Foro: Foro de São José do Rio Pardo
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 04/11/2022
... contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São José do Rio Pardo
Foro de São José do Rio Pardo
1ª Vara
Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500516-98.2022.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500516-98.2022.8.26.0575
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2209719/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 26514522 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2209719 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JOÃO VITOR GERALDO AFONSO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de João Vitor Geraldo Afonso, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, eis que no dia 03 de agosto de 2022, por volta das 07h10, na Avenida dos Braghetas, Carlos Cassucci, nesta cidade e comarca, João, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado, vendia e trazia consigo 36 (trinta

e seis) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 40,13g, 29 (vinte e nove) porções de crack, pesando 5,30 gramas, 12 (doze) porções de maconha, pesando 13,30 gramas, 06 (seis) comprimidos de ecstasy, pesando 2,5 gramas, 04 (quatro) selos de LSD, pesando 0,01 gramas, e 01 (um) frasco contendo 100ml de lança-perfume caseiro, conhecido como Loló, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Liberdade Provisória concedida - págs. 45/50.

A denúncia de págs. 41/43 veio amparada no Inquérito Policial - Prisão em Flagrante - de págs. 01/35.

O réu foi notificado em audiência (págs. 45/50) e apresentou defesa prévia (págs. 81/84), alegando ser apenas usuário de entorpecentes. Alega a inexistência de provas seguras no tocante a autoria do delito.

A denúncia foi recebida aos 22 de agosto de 2022, designando-se audiência de instrução. (págs. 86/88).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório do acusado, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada no SAJ.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Após exposição da prova oral coligida concluiu que os policiais foram coesos e nada indica que pretendem incriminar injustamente o réu. Quanto a este, embora tenha se declarado usuário de maconha e cocaína, não haveria qualquer explicação para a existência de crack, ecstasy, lança-perfume e LSD consigo. Requer o aumento da pena base na primeira fase, diante da variedade de entorpecentes. Indica a menoridade relativa e reputa possível a incidência da causa especial de diminuição de pena, resultando em regime aberto - pgs. 182/186.

A defesa, por sua vez, sustenta a mera condição de usuário do réu que mora próximo ao local dos fatos. O dinheiro apreendido é fruto de venda de roupas em parceria com sua tia Elisângela Bento. Ressalta a primariedade do réu. Alternativamente, requer a fixação da pena mínima, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, impondo-se o regime aberto - pgs. 187/191.

DECIDO.

1 -) SÍNTESE PROBATÓRIA

1.1 -) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 14/15), auto de constatação preliminar (págs. 16/21), além dos laudos periciais (págs. 117/119, 120/122, 123/125, 126/128; 163/171 e 173/175), que indicam que a massa líquida da substância foi de 8,5 + 4,1 + 9,7, totalizando 22,3 gramas e 74 mililitros.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

2.2 -) Das provas da autoria.

Rivaldo Luciano Tonhão informa que o local é biqueira do "Bronx", conhecido pelo grande volume de tráfico de drogas. Avisaram 2 indivíduos fazendo transação com um veículo. Dois moleques correram no pasto e o Parra fez o cerco. Um deles evadiu-se e João Vítor foi abordado de posse de uma pochete. Encontrou o celular do réu. Havia R\$ 108,00, em notas fracionadas e as drogas indicadas na denúncia. O réu confessou a traficância e falou que há 3 dias estava traficando ali no Bronx. Não conhecia o réu de outra ocorrência. A pochete estava com o réu pessoalmente e não apenas no local da abordagem. O réu não se declarou como usuário de drogas. Ele reside próximo ao local.

João Paulo Gonçalves Parra informa que o local é conhecido como Bronx, de intenso tráfico de drogas. A equipe deparou-se com 2 indivíduos na biqueira e com a chegada da viatura eles correram para a área de mata. Perderam um de vista e abordaram apenas o réu. Com ele havia a pochete com as drogas. Ele disse que estava traficando há 3 dias ali. Havia dinheiro com ele. Ele mora nas proximidades. Ele estava na posse da pochete. É prática comum na biqueira, cada um ficar com a sua "cota", presa ao corpo ou escondida. Depende da pessoa que está na fuga. No caso do réu, por causa da quantidade ser grande o prejuízo seria grande.

Daniela Aparecida Correa Cunha não viu a abordagem da polícia e conhece ele desde criança. Não sabe se ele usa droga. Não sabe se ele trabalha. Ele frequenta a casa da depoente e é boa pessoa. Nunca ouviu que ele estivesse envolvido com vendas de drogas. Ficou surpresa. O réu foi criado com os filhos da depoente. Conhece ele desde 2010. A família são todas pessoas boas e ficou surpresa é muito triste. Tem ele como filho.

Elisângela Cristina Elizei Bento Geraldo é tia do réu. Não viu quando a polícia abordou o João. Ele é usuário de maconha. Ele não trabalha. O réu mora perto do local da abordagem. Ele não falou com a depoente sobre a droga depois que foi solto. Passou R\$ 120,00 para ele, um dia antes.

O réu, João Vitor Geraldo Afonso, 20 anos. Estudou até o terceiro ano. Começou a lixar peças de carro com seu tio, depois do problema. Mora com sua mãe, padrasto e irmão. Usa maconha e cocaína. Ouviu o que os policiais disseram. Saiu de casa cedo, 7 e poquinho, subiu para o Bronx e pegou a cocaína porque seus familiares trabalham cedo e então usa nesse horário. A maconha eles sabem que o depoente usa. O moleque estava lá embaixo e o depoente estava usando e o moleque passou correndo e gritou que tinha polícia. O depoente correu também, mas passou mal e parou. Não reagiu. O outro moleque fugiu. Os policiais foram no local onde o moleque estava, agachou e achou a droga. Não conhece o moleque. Não falou que estava vendendo drogas há três dias. É morador do bairro há 20 anos.

2 -) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois "goza de presunção de credibilidade".

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada.” (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO,

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial. Em suas versões, os policiais narraram claramente atos de traficância.

Nada faz crer que os policiais estejam agindo imbuídos por sentimentos subalternos dignos de censura tendentes a elucubrar versão incriminadora para aprisionar injustamente pessoas com as quais não mantêm qualquer relação de desafeto comprovada.

Por outro lado, em que pese a presunção de inocência e a possibilidade dogmática de incidência do benefício da dúvida é preciso lembrar que o artigo 156 do Código de Processo Penal é categórico no sentido de que "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos elementos presentes no processo e não no âmago psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaque do Juízo)

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

As testemunhas de defesa não presenciaram a ação policial. Destarte, não oferecem realidade diversa daquela apresentada pelos policiais em seus depoimentos.

No que tange à alegada drogadição é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ª Turma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Como bem apontado pelo Ministério Público, "Ainda que o acusado tenha informado ser usuário de maconha e cocaína, foram encontradas outras drogas em poder dele: crack, ecstasy, lança-perfume e LSD. Evidente, portanto, que elas não se destinavam ao seu consumo."

A respeito da citação de trecho da argumentação acusatória, prudente dizer que é pacífico no âmbito do STF e do STJ o entendimento de ser possível a fundamentação per relationem ou por referência ou por remissão, não se cogitando nulidade ou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, desde que os fundamentos existentes aliunde sejam reproduzidos no julgado definitivo (principal). Neste sentido: E. STF: MS 27350 MC/DF, Relator Min. Celso de Mello, DJ de 04.06.2008; Emb. Decl. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo nº 692.087/DF, 1ª Turma do STF, Rel. Rosa Weber. j. 12.08.2014, unânime, DJe 29.08.2014 e no STJ: REsp 1.426.406/MT, Rel. p/Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 11.05.2017).

Assim, cabível a reprodução dos principais trechos apontados pela acusação e que estão amparados no acervo probatório coligido durante a instrução processual.

Pertinente sinalizar, ainda, que a própria Lei admite tal técnica de fundamentação. A propósito, tem-se o § 3º do art. 2º do Decreto 9.830/2019 que regulamentou os artigos 20 a 30 da Lei de Introdução às Normas no Direito Brasileiro - Lei 4.657, DE 04/09/1942 cuja dicção é a seguinte: "§ 3º A motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que precederam a decisão." (destaques do Juízo). Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

3 -) DO DISPOSITIVO E DOSIMETRIA DA PENA

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 41/43, para CONDENAR JOÃO VITOR GERALDO AFONSO pela prática do crime capitulado no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, c.c o artigo 29, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo.

O critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 22,3 gramas e 74 mililitros, conforme págs. 117/128.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

Analisando estes itens o Juízo encontra campo para necessário acréscimo, pois a quantidade-variedade de drogas diferentes (no caso seis - cocaína, crack, maconha, ecstasy, LSD e lança-perfume) impõem aumento de pena, uma vez que o traficante que tem consigo uma variedade de tóxicos está pronto a atender parcela de usuários mais ampla, alcançando "maior clientela" e demonstrando nível superior de periculosidade do que aquele que fornece apenas uma espécie de droga. Assim, deve receber a reprimenda diferenciada em estrita observância ao mandamento constitucional de individualização da pena.

Ademais, o réu tinha consigo drogas "exóticas", absolutamente incomuns nesta cidade, o que evidencia seu know-how em obtenção de tais entorpecentes "especiais" e sua distribuição nesta cidade.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base privativa de liberdade para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, 2/6 (dois sextos) acima do mínimo legal, por força da natureza e da diversidade de entorpecentes estabelecendo-a em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 dias-multa.

Diante da menoridade relativa, atenuo a pena em 1/6, baixando-a ao patamar de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa.

Aplicável a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o réu é primário e a quantidade de entorpecentes não é suficiente para indicar ligação a organização criminosa deve ser beneficiado com o redutor em seu patamar máximo, pois a variedade de entorpecentes já foi considerada na primeira etapa e não pode representar bis in idem.

Deste modo, reduzo a pena em 2/3 fixando-a em 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão e 185 dias-multa.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA a pena supra.

O dia-multa tem o valor unitário equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, observado o disposto no artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Quanto ao regime prisional impõe-se prontamente reconhecer que na sessão do dia 23.06.2016, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. A discussão ocorreu no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, que foi deferido por maioria dos votos.

O próprio Ministério Público não discordou. O parecer do subprocurador-geral da República Edson de Oliveira Almeida contém o seguinte trecho:

"A questão da hediondez do "tráfico privilegiado" está afetada ao Plenário (HC nº. 110.884/MS), aguardando julgamento. É certo que nos crimes de tráfico de drogas é necessário que o réu cumpra 2/5 da pena para obter a progressão de regime (art. 2º, § 2º, da Lei nº. 8.072/9) e 2/3 da pena para fins de livramento condicional (art. 44, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, e art. 83, V, do Código Penal). Contudo esses prazos maiores se aplicam apenas aos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 34 a 37 da Lei 11.343/2006, sem abranger as condutas punidas pelo § 4º do art. 33, que têm menor grau de reprovabilidade e, portanto, não podem ser qualificadas pela hediondez. Onde, condenados os pacientes por tráfico privilegiado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, o resgate de 1/6 e 1/3 da pena, para a progressão de regime e livramento condicional, a teor dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e art. 83, inciso I, do Código Penal, respectivamente."

Evidentemente que as instâncias ordinárias deverão observar se o entendimento se firmará e quais serão seus demais contornos e reflexos. Ressalvo, ainda, meu posicionamento pessoal sobre a maior adequação do regime inicial fechado para os casos de tráfico de entorpecente, que se sustentava, entretanto, também em sua equiparação a crime hediondo.

O Egrégio STJ revogou sua súmula 512 para acompanhar o entendimento do E. STF e tem reiteradamente concedido habeas corpus contra decisões do E. TJSP.

No Habeas Corpus nº 457.359/SP (2018/0162657-9), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 23.08.2018 o E. STJ reafirmou a mudança de posicionamento quanto ao tema por parte da Quinta e Sexta Turmas daquela Corte Superior, que culminou na revisão do entendimento anteriormente consolidado, pela Terceira Seção, e no cancelamento do Enunciado nº 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: Habeas Corpus nº 391.654/SP (2017/0052379-4), STJ, Rel. Maria Thereza de Assis Moura. DJe 05.06.2017; Habeas Corpus nº 394.704/SP (2017/0074889-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 31.05.2017; Habeas Corpus nº 386.049/SP (2017/0013012-3), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. DJe 19.05.2017.

A este respeito também é devida observância à súmula 440 do STJ, bem como 718 e 719 do STF, as quais também orientam a fixação do regime, ou ainda o teor da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal.

Eis o teor das súmulas citadas:

SÚMULA Nº 440 Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

SÚMULA Nº 718 A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o

permitido segundo a pena aplicada.

SÚMULA Nº 719 A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Com tais fundamentos, fixo o regime ABERTO, considerando os precedentes supra, primariedade do réu, menoridade relativa e ausência de indicação de sua periculosidade.

Inviável, no entanto, a substituição da pena, a despeito da resolução nº 5/2012 do Senado Federal. Neste ponto, anoto que malgrado o assentado, v.g, no HC. 101.291 – SP, relatado pelo Ministro Eros Grau no Supremo Tribunal Federal, cerro fileiras com o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no incidente de arguição de inconstitucionalidade no habeas corpus nº 120.353 – SP, cujo relator é o Ministro Ari Pargendler, pois a individualização da pena é tarefa que incumbe primeiramente à lei e disso o legislador se desincumbiu engendrando a proibição citada no dispositivo invocado.

No mais, tenho por irretorquíveis os argumentos de Sua Excelência no sentido de que “se a lei deve assegurar indiscriminadamente ao juiz o arbítrio para, no caso do tráfico ilícito de entorpecentes, substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, o próprio artigo 44 do Código Penal seria inconstitucional ao excluir desse regime os crimes cometidos à base de violência ou grave ameaça à pessoa – e com maior razão.”

Em meu entendimento, não se afigura socialmente recomendável a reinserção de traficantes ao convívio social indicando-lhes instituições públicas (escolas, asilos, centro de saúde, etc) para prestar serviços comunitários.

Ademais, considera-se que o tráfico de drogas é crime que revela grave ameaça à sociedade, portanto, com maior razão, não poderia comportar a substituição por penas restritivas de direito.

Ausente, portanto, o requisito do inciso III do art. 44 do Código Penal (suficiência da substituição).

No mesmo diapasão: Apelação nº 001224186.2010.8.26.0153, comarca de Cravinhos. Rel. Francisco Bruno, j. 16.06.2011; Apelação 990.09.063232-1, comarca de São José dos Campos. Rel. Newton Neves, j. 17.05.2011.

O descumprimento do regime aberto (adequado segundo o STF e STJ), por outro lado, pode prontamente ensejar o encarceramento por regressão ao semi-aberto e, posteriormente, até para o regime fechado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão observando o regime fixado adotando-se, previamente, as providências indicadas na recomendação 417/2021 CNJ – art. 23, com a redação da recomendação 474/2022 CNJ. Faculta-se ao réu apresentar-se em Juízo no horário das 13:00 às 16:30 durante os dias úteis, ocasião em que sua audiência admonitória será "encaixada" na pauta regular, evitando-se o cumprimento de mandado de prisão em regime aberto pela Polícia a fim de prevenir eventuais intempéries que excepcionalmente podem ocorrer em situações análogas; Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal; Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação,

com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;
Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;
Autorizo a restituição do numerário apreendido, diante da declaração de pgs. 85 e depoimento de Elisangela Cristina Elizei Bento Geraldo, suficientes a deixar dúvidas sobre a origem ilícita do numerário. Destarte, resta favorecido o réu neste ponto específico.
Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA